

版权所有 © 不可随意转载

本篇重点主要来自qy和ygp老师，具体内容参考qy老师上课内容。

要硬背诵的部分会用红色背景。

大致背诵的部分会用绿色背景。（大部分为帮助案例分析/判断时写理由的）

红色为必记事项

酒红色为加深印象，尽量背记

法条用该颜色标出，注意看下对应法条是否出现在所买的法条目录里

该颜色为例子

和考试有关的注意事项用该颜色标出

该颜色帮助理解

题型和答题要求

1. 判断题Ⅰ（每题2分，共16分；判断下列条文中划线部分的行政活动性质）
2. 判断题Ⅱ（每题3分，共24分；判断以下句子的内容是否正确，正确的在后面括号中打√，不正确的打×；如认为错误的，请简要说明理由）
3. 简答题（每题12分，共24分；今年没有名词解释，对于个别名词理解和运用会以别的形式来展开考察，默写名词概念没有）
3. 案例分析题（每题12分，共36分）

涉及板块：行政法的原则，渊源，具体行政行为类型，许可处罚强制；行政检察，征收征用，行政指导；政府信息公开制度等

知识板块

行政法的基本原则

行政法的渊源（包括规范性文件）

行政主体

行政行为

行政许可法

行政处罚法

行政强制法

其他行政行为（行政检查、行政征收、征用、行政协议、行政给付、行政奖励等，包括事实行为）

行政程序（包括政府信息公开制度）

总的来说，考题以对法条明文规定的理解和适用为主要部分，加上部分基本原理的理解和适用。

零、其他

行政活动行为性质会判断：

(1) **行政处罚**：行政机关依法对违反刑侦管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒。

(2) **行政许可**：行政主体根据行政相对人的申请，以颁发特定证照等方式，依法赋予行政相对人从事某种活动的法律资格或实施某种行为的法律权利的具体行政行为。

(3) 行政强制：

A) **行政强制措施**：行政强制措施，是指行政机关为了防止和制止可能发生和正在发生的危害和违法行为，或者进行行政调查，对公民、法人或其他组织的人身、财产等采取的强制手段。

B) **行政强制执行**：行政强制执行是指公民、法人或其他组织不履行行政机关依法所作行政处理决定中规定的义务，有关国家机关依法强制其履行义务或达到与履行义务相同状态的行为。

(4) 行政征收与征用

A) **行政征收**：行政主体为了公共利益的需要，依法强制取得财产所有权，并给与相应补偿的行政行为。

B) **行政征用**：行政主体为了一定的目的，依法强制地使用他人的财产或者对有关劳务进行征用并给予相应补偿的行政行为。

【帮理解】二者区别：

第一，产生的法律后果不同。征收是对相对人财产权利的永久性消灭或转移；而征用则是对私人财产使用权的临时性剥夺，具有期限性。

第二，适用条件不同。征用多在紧急状态下使用。

第三，客体不同，在中国目前的法律框架下，征收的对象以不动产为主；而征用的对象则比较广泛，即可以是房屋、土地不动产，也可以是各类动产。

(5) **行政给付**：行政主体在特定情况下，依法向符合条件的申请人提供物质利益或赋予其与物质利益有关的权益的行为。

(6) **行政奖励**：行政主体为了实现一定的行政目标，依照法定条件和程序赋予行政相对人物质、精神或其他特别权益，激励、引导行政相对人实施符合政府施政意图行为的行政行为。

(7) **行政检查**：行政主体基于行政职权，对相对人执行法律、法规和规章以及有关行政命令、行政处理决定的情况进行单方面强制了解的行政行为。

(8) **行政指导**：行政主体通过建议、劝导、告诫、激励等非强制性手段引导行政相对人作出或不作出一定行为，在为行政相对人提供信息服务和对相对人进行说服教育的过程中柔性实现行政管理的目标和任务。

(9) **行政确认**：行政主体对行政相对人的法律地位、法律关系或者法律事实进行甄别，依法给予确定、认可或证明并予以宣告的行政行为。

(10) **行政裁决**：国家行政机关根据法律、法规的授权，以居间裁决者的身份，对特定范围内与裁决机关行政管理职权密切相关的民事纠纷依法作出处理的行政行为。

一、行政法基本概念

(一) 行政法基本内涵 (了解)

1. 行政法：调整在公共行政的组织、活动、程序、监督和救济等方面所产生的各种社会关系的法律规范的总称。 (规范和约束行政权的法)

行政法的核心：对政府权力的控制

2. 特点

- (1) 调整行政法律关系的法
- (2) 规范行政固有领域的法 有行政权运行的领域
- (3) 有关行政的国内法

3. 功能

- (1) 保护公民、法人和其他组织的合法权益 (因为行政主体和其他公民或组织的关系中，后者属于绝对弱势地位)
- (2) 监督行政主体的行政行为，避免、阻止行政专横
- (3) 维护行政机关依法行使行政权力，促进良好社会秩序的实现
对网约车进行限制，赋予行政主体处罚权、强制权等等

(二) 行政法律关系 (理解)

1. 行政法律关系：由行政法律规范确认和调整的因行政权力的行使而在行政主体和其他当事人之间产生和形成的权利义务关系

(1) 前提：基于行政权的行使而形成 交警行政处罚权的行使才有处罚款的行政法律关系；eg 市人大对市政府的规范性文件进行审查 不是行政法律关系 (是基于立法权进行审查)

(2) 行政主体和其他当事人之间各自享有权利，并承担义务

警察：实施罚款的权利+调查取证的义务；

当事人：知情权/申辩权/复议等行政救济权+实施行政处罚结果的义务

2. 分类

(1) 行政权力的范围不同：内部行政法律关系和外部行政法律关系

内部：上下级、行政主体和公务人员… 工作人员实施违纪行为进行的辞退

外部：(主流) 行政主体和外部行政相对人 行政处罚、强制、许可、征收

(2) 法律关系属性不同：行政实体法律关系和行政程序法律关系

实体：受到实体法律规范调整，而形成的实体上的权利义务关系

程序：受到程序法律规范调整，而形成的程序上的法律义务关系

● 二者密切交织

(3) 法律关系的形成原因：原生行政法律关系和派生法律关系

原生：由行政权的行使直接产生的行政法律关系 查封房子行政强制法律关系

派生：由行政权的行使间接产生的行政法律关系 对查封决定不满产生的行政复议法律关系

【例】某日，张三和李四由于邻里纠纷发生争执，争执过程中，居委会主任王五赶来进行调解，但未产生效果。张三情绪激动之下开始对李四进行殴打，李四被打得鼻青脸肿。此时松江公安分局的民警赵六接到报案赶来，制止了张三的殴打行为，并对张三作出了拘留十日的行政处罚。张三对该处罚结果不服，于是向松江区政府提起了行政复议，松江区政府受理了该复议申请。——问：本案中存在着哪些行政法律关系？行政处罚法律关系；行政复议法律关系。

二、行政法的基本原则★★★（重点背记，因为法条没有，且说理要用）

（理解适用情形-案例分析会考体现了什么原则：了解主要内容与实践运用）

（一）职权法定原则

1. 概念：行政机关行政职权的来源、存在依据和权力要求是法定的，法律之外不享有行政职权，否则将被宣告无效并承担相应法律责任。

核心：行政机关：法无授权即禁止

2. 来源：宪法 or 行政机关组织法

3. 要求

（1）一切行政职权皆来源于法律的授予【来源法定】

（2）行政活动必须依据法定职权进行，越权无效【行使合法】

（3）法定的行政职权必须得到积极、充分的行使【权责一致】

（公民对权利具有处分的自由，但是行政机关没有）

（二）法律优位原则

和上位法违背时情形

1. 概念：一切行政活动都不得与法律相抵触（消极的依法行政）。

2. 要求：

（1）法律优位原则所指的“法律”是指狭义的法律，即由最高国家权力机关（人大及其常委会）制定的规范性文件

（2）法律的效力高于一切行政行为

（3）不得违反法律：并非一切行政行为都能找到法律依据，存在缺位的法律时，行政法规、地方性法规、部门规章等可在自己的立法权限内作出行为，作为补位，但★不可违反上位法律。

（三）法律保留原则

限制人身自由等，只能由立法规定

1. 概念：要求一定范围内的行政活动必须有法律的明确根据（法律的授权）。（积极的依法行政）（特定事项，行政机关不能规定，只有立法机关才能规定）

2. 范围

- (1) 侵害保留说：凡是侵害和干预公民自由和财产的应该被纳入保留范围
- (2) 完全全面保留说：所有行政活动都要受到保留原则限制
- (3) 重要事项保留说：行政范围内的重要事项受保留原则限制

3. 我国法律保留：考试找《立法法》第11、12条

《立法法》第十一条 下列事项只能制定法律：

- (一) 国家主权的事项；
- (二) 各级人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；
- (三) 民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；
- (四) 犯罪和刑罚；
- (五) 对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；
- (六) 税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；
- (七) 对非国有财产的征收、征用；
- (八) 民事基本制度；
- (九) 基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；
- (十) 诉讼制度和仲裁基本制度；
- (十一) 必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

第十二条 本法第十一条规定的事项尚未制定法律的，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施（★该项为绝对法律保留）和处罚、司法制度等事项除外。

（四）正当程序原则

相对人知情权、参与权被剥夺

1. 程序：按时间先后或依次安排的工作步骤，是对交涉过程的制度化
2. 法律程序：被强制遵循的程序
3. 正当程序：符合特定价值追求的法律程序
4. 要求：

- (1) 公正性：具有裁决权的主体确保公正性
- (2) 透明性：行政权力的行使在阳光下
- (3) 互动性：相对人★有机会充分陈述和表达意见

（五）比例原则——属合理性（不是合法性）

可能合法但是不合理 eg. 罚款数额过大/无需强制但是非要强制

1. 概念：行政机关在作出裁量行政行为时，全面衡量私益和公益之间的关系，并最终采取对行政相对人侵害最小的方式进行，不能超过必要限度。
2. 内容

- (1) 妥当性

【新闻 盲人练字一年才办成离婚】离婚“当事人领证签名并按指纹”，老太太是盲人且手因风湿病变形。

(2) **必要性**：★ 行政机关要保证所采取的行政手段再诸多可供选择的手段中是侵害最小的（应该确保所选择的手段是达成目的的必要条件）

(3) **法益相称性**：行政机关干预的严厉程度与理由的充分程度之间要非常成比例。（一方面损害了相对人的某种法益，另一方面保护了某种利益，两种要相当）
比例原则：【陈宁诉庄河市公安局行政赔偿纠纷案】

（六）信赖保护原则

可能有关 行政许可，变更和撤回/行政协议

(1) 什么是信赖利益：(1) 该利益的产生是基于行政相对人对政府的信赖 (2) 该利益值得法律保护

【港资企业投资自来水公司治理城市污水处理】

当地政府为了促成投资非常积极，甚至制定了规章。但是最后因为违反国务院规章废除该规章。

(2) 如何保护信赖利益？★

- ① 行政机关的活动不得武断专横、反复无常
- ② 行政机关不得制定对公民产生不利影响的具有溯及力的规范性文件
- ③ 行政机关依法撤销或废止具体行政行为后，要保护公民因对行政机关的正当信赖而获得利益

三、行政法的渊源 翻《立法法》

不同成文法的制定主体+效力层级，设定权的问题

效力从高到低——

1. 宪法
2. 法律：行政处罚法、行政许可法、行政强制法

《立法法》第十条 ←考试找

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会根据宪法规定行使国家立法权。

全国人民代表大会制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。

全国人民代表大会常务委员会制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。

全国人民代表大会可以授权全国人民代表大会常务委员会制定相关法律。

3. 行政法规：国务院

《立法法》第七十二条 ←考试找

4. 地方性法规

《立法法》第八十条、第八十二条 ←考试找

5. 自治条例和单行条例

《立法法》第八十五条 ←考试找

6. **经济特区法规、浦东新区法规、海南自由贸易港法规**【效力上与地方法规层级相同，形式是授权立法】

《立法法》第八十四条 ←考试找

7. **规章：部门规章**

《立法法》第九十一条；《立法法》第九十二条

8. **法律解释**：法律解释是法律在具体运用的过程中，为进一步明确内容，使相应的规范内容更加具有可实施性所作的解释（立法解释效力和法律一致）。

9. **国际条约**：国际条约是国际法主体之间以国际法为准则，为确立其相互间权利和义务缔结的书面协议。

《最高人民法院关于审理国际贸易行政案件若干问题的规定》第九条：人民法院审理国际贸易行政案件所适用的法律、行政法规的具体条文存在两种以上合理解释，其中有一种解释与中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的有关规定相一致的，应当选择与国际条约的有关规定相一致的解釋，但中华人民共和国声明保留的条款除外。

10. **行政规定**

上海市教育委员会等颁布《上海市成人培训机构设立与管理实施办法》
规章以下的规范性文件

四、行政主体（会判断并说理由）

内涵和分类、主体的性质判断（是否是行政主体？是授权还是委托？）

（一）行政主体

1. 概念：行政主体是指享有国家行政权，能以自己的名义行使行政权，并能独立地承担因此而产生的相应法律责任的组织。

2. 要件

（1）行政主体是一种组织，而非个人

A市城管队员小明在巡查时发现一处售卖水果的无证摊贩，于是对该小贩做出了罚款500元的处罚决定。——小明是不是行政主体？不是。

（2）行政主体是享有国家行政权的组织

法院不是行政主体（行使司法权而不是行政权）

小明要求小贩以现金方式支付500元罚款，并将罚款私吞。小贩随后向当地监察委员会举报，监察委员会对小明做出了警告处分。——监察委员会是不是行政主体？不是。行使监察权而不是行政权

（3）行政主体是能够以自己的名义行使行政权的组织

此事引起了A市市长的关注，于是A市政府办公室起草了一份关于进一步规范本市罚款程序的规范性文件，并以市政府的名义对外发布。——市政府办公室是不是行政主体？不是。因为其无法以自己的名义对外发布

（4）行政主体是能够独立承担法律责任的组织。（在行政复议能作为被申请人、在诉讼中作为被告等）

此事发生后，A市城管深感执法能力有所不足，于是作出决定，将部分行政处罚委托给B县城管中队行使。——B县城管中队是行政主体吗？不是。行使只是受委托组织，权力并不是自己的，最终法律后果也是归于委托方。

3. 我国的行政主体

(1) 中央行政机关：活动范围及管辖事项涉及全国的行政机关

组成名称	设立、撤销、变更程序	法律权限	法律地位
国务院	由全国人大选举，并对其负责受其监督	是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关	行政主体
国务院各部委	国务院总理提请全国人大决定；人大闭会期间，提请全国人大常委会决定。	1) 执行国务院行政法规决定命令并依此行使职权； 2) 部门规章制定权。	行政主体
国务院直属特设机构	国务院总理提请全国人大决定	按国务院授权并依照《公司法》等法律规范代表国家履行出资人职责	行政主体
国务院直属机构	根据工作需要和精简原则，由国务院自行决定	1) 制定规章权； 2) 所管辖事务的管理权； 3) 裁决法律争议权。	行政主体
国务院办事机构	根据工作需要和精简原则，由国务院自行决定	辅助总理办理专门事务的机构	不具备行政主体资格
国务院直属事业单位	经有权机关批准、履行社团登记手续		法律授权范围内具有行政主体资格
国务院部委管理局	根据工作需要和精简原则，由国务院自行决定	主管有关行业或者行政事务	行政主体

(2) 地方行政机关

① 地方各级人民政府：【职权】执行权；具体行政管理权；规章的制定权

地方人民政府分为省（自治区、直辖市）、市（自治州）、县（自治县、市辖区及不设区的市）、乡（民族乡、镇）四级。

② 地方各级人民政府的职能部门 xx厅；xx委员会/xx发改委

【职权】（对管辖范围内的事务）发布命令和指示；对行政事项的主管权

例 某日，A县公安局治安科的科员小王针对张三做出了治安拘留五日的行政处罚。

——在此行政处罚行政法律关系中，谁是行政主体？A县公安局

③ 地方人民政府的派出机关：行政公署、区公所、街道办事处

（二）法律、法规授权的组织

概念：根据法律法规授权行使行政职能的国家机关之外的组织。

A. 什么是法律、法规？

1. 界定

(1) 法律：全国人大及其常务委员会制定的规范性文件。

(2) 法规：行政法规、地方性法规

2. 规章能不能授权？——规章授权组织原则上不具有行政主体资格，但为了事实需要，也在实际生活中被认定为行政主体，可以成为被告。

《行政复议法》第2条 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，向行政复议机关提出行政复议申请，行政复议机关办理行政复议案件，适用本法。

前款所称行政行为，包括法律、法规、规章授权的组织的行政行为。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第24条 当事人对村民委员会或者居民委员会依据法律、法规、规章的授权履行行政管理职责的行为不服提起诉讼的，以村民委员会或者居民委员会为被告。……当事人对高等学校等事业单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协会依据法律、法规、规章的授权实施的行政行为不服提起诉讼的，以该事业单位、行业协会为被告。

B. 什么是授权？

1. 法规、法规直接规定将某项或者某一方面的行政职权一部分或者全部授予某个组织。【直接规定授权内容】

《工商行政管理所条例》第8条第一款：工商所的具体行政行为是区、县工商局的具體行政行为，但有下列情况之一的，工商所可以以自己的名义作出具体行政行为：

（一）对个体工商户违法行为的处罚；（二）对集市贸易中违法行为的处罚；（三）法律、法规和规章规定工商所以自己的名义作出的其他具体行政行为。

2. 法律、法规规定由特定的行政主体通过法定的方式将某项或者某一方面的行政职权一部分或者全部授予某个组织。【规定可授权的机构】

《中华人民共和国学位条例》第8条第一款：学士学位，由国务院授权的高等学校授予；硕士学位、博士学位，由国务院授权的高等学校和科研机构授予。

C. 什么样的组织可以被授权？

★★★**内设机构、派出机构，没有授权的情况下无法作为适格行政主体。**

1. 法律法规授权的行政机构（本身不享有行政主体的编制和经费，不作为行政主体，法律后果也由背后的行政机关承担。但是某些时候经过一定授权，则会发生身份转变）

（1）内设机构

国家工商行政管理局内设的商标局

县级以上公安机关内设的交通警察队和消防监督机构

（2）临时机构

国家防汛指挥部

新冠肺炎疫情防控指挥部

山东“馒头办”

（3）派出机构

★★★**派出机关有行政主体资格**

派出所、税务所、工商管理所、财政所

《治安管理处罚法》第九十一条：治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定

【区别】派出机构 vs 派出机关

	派出机关	派出机构
设立机关不同	某级政府	政府的工作部门设立
行使职权不同	一般行政职权 (一般权限的行政机关)	某方面的行政职权 (部门权限的行政机关)
种类多少不一	行政公署、区公所、街道办事处	派出所、税务所、工商所
法律地位不一	行政主体地位	一般无行政主体地位； 在法律、法规授权的情况下， 可成为行政主体——法定授权的组织。

2. 法律、法规授权的其他社会组织

- (1) 经授权的企业单位 Eg 国家铁路运输企业
- (2) 经授权的事业单位 Eg 高等学校和科研机构；中国疾病预防控制中心
- (3) 经授权的社会团体 Eg 律师协会

(三) 行政机关委托的组织

★★★委托方是行政主体，而非受托方

1. 定义：是指受行政机关的委托，以委托者的名义行使一定行政职权的组织。
2. 特点：
 - (1) 受委托组织的范围较为广泛；
 - (2) 受委托组织不承担因委托行为而产生的法律责任；
 - (3) 受委托组织行使的行政职权要受严格的限制。

【李春诉大安市人民政府行政征收案】法院认为由于政府征收行为批准文件未下达，是前置行为，未对相对人的权利义务产生实际影响。再审最高院认为，市政府作为法定的征收主体，其征收行为和施工方占地行为不可分割（施工方敢这样做是仰仗着市政府的征收公告），应视为市政府与施工方存在委托关系，由大安市政府承担法律责任。

五、行政行为

概念、定义、行为成立、生效要件（案例分析判断是否是行政行为）；撤销改变无效

(一) 基本概念

1. ★★★ 判断什么是行政行为：

- (1) 行政行为主体是行政机关
- (2) 行政主体在行政管理过程中，实施行政权所为的行为
- (3) 行政行为能产生法律后果：对当事人权利义务产生影响

【区别】区别于行政事实行为

E.g. ★★ 统计局发布统计数据的行为是事实行为

E.g. ★★ 气象局发布的天气预报的行为是事实行为（只是参考 没有强制力无法律效果）

E.g. 交警指挥交通的行为是行政行为（有强制力，有法律后果）

2. ★ 抽象/具体行政行为的区分

- (1) 抽象行政行为：行政主体以一类事、一类人为对象制定行政规范的行为。（行政法规、规章、规范性文件）
- (2) 具体行政行为：行政主体对特定的具体事件所做的能直接改变被管理者权利与义务的行为。（行政处罚、行政强制、行政许可等）

【区分标准】抽象行政行为和具体行政行为的区分标准

第一，对象是否特定。并非行为一定指向某一一人，指向特定的某一群体也是对象特定，如强制房屋征收。

第二，行为是否可以反复适用。具体行政行为不可反复适用，如罚款交完后行政行为效力消灭，不可反复适用。

第三，该行为是否直接改变被管理者的权利义务或法律地位。抽象行政行为不会直接改变，需要通过执行性手段，是间接的效果。具体行政行为直接发生效果，以强制执行为保障

案例

某市原有甲、乙、丙、丁四家定点屠宰场，营业执照、卫生许可证、屠宰许可证等证照齐全。后来，国务院发布《生猪屠宰管理条例》，该市政府根据其中确认并颁发定点屠宰标志牌的规定发出通告，确定只给甲发放定点标志牌。据此，市工商局将乙、丙、丁三家屠宰场营业执照吊销，卫生局也将卫生许可证吊销。乙、丙、丁三家屠宰场对此不服，找到市政府，市政府称通告属于抽象行政行为，需遵守执行。三家屠宰场遂提起行政诉讼。

问：市政府的通告属于何种类型的行政行为？理由是什么？

——具体行政行为，对象特定是甲，不可反复适用，直接赋予甲的权利意味着直接剥夺了另外三家的经营权利

(二) 行政行为成立、生效等

1. 行政行为成立要件

- (1) 主体要件：行政行为必须由行政主体作出。

- (2) 内容要件：行政主体应当通过一定的方式对被管理者的权利与义务作出处分。
(包括对权利与义务的认定予以法律上的保护 并非一定增减 如不动产抵押的登记)
- (3) 形式要件：对于要式行为而言其形式要件缺乏不可导致相应法律效果

2. 行政行为生效要件

(1) 具体行政行为的生效要件

告知：行政主体通过一定方式将行政行为通知行政相对人或相应权利主体（方式从法定，无法定自己选择，重点在于要让相对人清楚明确意思表示）

受领：【时点的确认】口头方式——当场受领，书面方式——送达回执或相应文书上签字，留置——拟制送达，公告——公告期限届满

(2) 抽象行政行为的生效要件

发布：公共媒介上发布时视为受领。行为生效的时间未必是发布的时间，一般文件会规定具体生效时间。

3. 行政行为的效力

(1) 内容

- ① 拘束力：行政行为的拘束力，是指行政行为一经生效，就对有关当事人具有约束的效力。（行政主体、相对人、其他组织、人员）
- ② 确定力：行政行为的确定力，是指行政行为一经作出，非依法定理由和程序，不得变动的效力。（符合信赖利益保护原则）
- ③ 执行力：（行政行为的内容一旦生效，一定会被执行）行政行为的执行力，是指行政行为具有的依法采用一定手段使行为的内容得以实现的效力。

(2) 行政行为的变更【针对裁量行政行为】

概念：行政行为的变更，是指在行政行为作出以后、消灭之前（效力存续期间），法定机关按照法定程序改变不当行政行为内容的活动。

导致行政行为变更的原因→行政行为的不适当，也就是行政主体运用裁量权不当而导致的行政行为出现瑕疵。

注：① 行政违法行为应当撤销无效，不存在变更问题，因此在羁束行政行为中不存在变更。② 超出裁量幅度的行为（如最高1w元罚款实际罚了2w）不可直接进行变更，该行为直接违法，应当彻底否定效力。

(3) 行政行为效力的消灭

导致行政行为效力消失的情形主要包括行政行为的撤回、撤销、废止、失效、无效。

A. 行政行为的撤销：行政行为的撤销，是指有权机关针对违法或明显不当的行政行为，取消其效力的过程。

原因→行政行为违法或明显不当

程序：

- ① 在行政复议中，由复议机关依复议法所规定的程序予以撤销；
- ② 在行政诉讼中，由法院依行政诉讼法所规定的程序予以撤销。

后果→自始无效

B. 行政行为的无效：彻底否定，自始没有效力

行政行为的无效是指具有重大且明显违法的行政行为，自始不具有法律效力。

《行政诉讼法》第75条 ←考试找

行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释第99条

有下列情形之一的，属于行政诉讼法第七十五条规定的“重大且明显违法”：（一）行政行为实施主体不具有行政主体资格；（二）减损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据；（三）行政行为的内容客观上不可能实施（如根本不存在标的物）；（四）其他重大且明显违法的情形（如该行政行为不具有生效的条件）。

before 六七八：

许可处罚强制（案例分析）【多翻法条】

六、行政许可法

1. 概念：行政许可是指行政主体根据行政相对人的申请，以颁发特定证照等方式，依法赋予行政相对人从事某种活动的法律资格或实施某种行为的法律权利的具体行政行为。

2. 特征：

- （1）行政许可是依申请的行政行为；（处罚和强制是行政机关依职权主动做出的）
- （2）行政许可是授益性行政行为；
- （3）行政许可是对法律一般禁止的解除；（禁止所有人实施某种行为，再放宽标准允许部分人实施。准入的禁止。事前管理的手段）
- （4）行政许可是要式行政行为。

3. 行政许可设定权

- （1）法律：可以设定《许可法》第12条规定的所有许可事项；
- （2）行政法规：可以设定尚未制定法律的许可事项
- （3）国务院决定：必要时的临时性许可
- （4）地方性法规：可以设定尚未制定法律、行政法规的许可事项
- （5）省级人民政府规章：可以设定尚未制定法律、行政法规、地方性法规的许可事项；临时性（一年）

★【注意】地方性法规和省级政府规章：

- （1）不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；
- （2）不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可；（不可对市场准入设定过多限制）
- （3）设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。（避免地方保护主义）

4. 行政许可的听证【特别程序】

（1）依职权听证

《行政许可法》第四十六条 法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。

依职权听证的范围：

- ① 法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项
- ② 行政机关认为需要听证的涉及公共利益的重大行政许可事项。

(2) 依申请听证【权利，可以放弃】

《行政许可法》第四十七条 行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利（行政机关的义务，否则程序违法）；申请人、★【利害关系人的权利】利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。

申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。

依申请听证的范围：

行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系

(3) 听证程序

行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告；行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避；听证应当公开举行。举行听证时，审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由。

5. 利害关系人的权利

(1) 行政许可的审查程序：

《行政许可法》第36条规定：行政机关对行政许可申请进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩。行政机关应当听取申请人、利害关系人的意见。

(2) 听证程序中的权利（见上）

6. 撤回撤销条件

(1) 行政许可的撤销【针对违法情况，行政许可的做出阶段存在违法情形】

行政许可的撤销，是指作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据其职权，对行政机关及其工作人员违法作出的准予行政许可的决定，依法撤销其法律效力的行为。

《行政许可法》第69条

有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：

.....

(2) 行政许可的撤回【与违法无关，“补偿”】

《行政许可法》第八条（信赖保护原则）

公民、法人或者其他组织依法取得的行政许可受法律保护，行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可。行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止（如立法提高环境标准），或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要（如烟草专卖店的周围建造小学，烟草专卖零售许可证被撤回），行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可（撤回之前的许可无违法行为，因此不溯及

既往，撤回的效力从撤回决定作出开始）。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失损失的，行政机关应当依法给予补偿。

7. 信赖利益保护原则的体现：体现在行政许可法第八条的行政许可的撤回上。

8. 行政确认与行政许可的区别（会区分）

- (1) 行为的内容不同：确认是对事实状态的认定，不会直接让相对人获得某种利益
- (2) 行为的性质不同：确认是证明行为；许可是对一般禁止的解除
- (3) 行为的法律效果不同：确认的效果具有溯及力；许可的效力是向后的

七、行政处罚法

会找《行政处罚法》，要以2021年颁布的新版本行政处罚法为准。

1. 行政处罚的种类

《行政处罚法》第九条

- (一) 警告、通报批评；
- (二) 罚款、没收违法所得、没收非法财物；
- (三) 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；
- (四) 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- (五) 行政拘留；
- (六) 法律、行政法规规定的其他行政处罚。

2. 行政处罚法的设定规则：

根据《行政处罚法》的规定：

(1) （狭义）法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定【法律保留原则】；

(2) （国务院制定的）行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚；

《行政处罚法》第十一条

行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。

法律对违法行为已经作出行政处罚规定，行政法规需要作出具体规定的，必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。

法律对违法行为未作出行政处罚规定，行政法规为实施法律，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。行政法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。

(3) （享有地方立法权的地方人大所制定的）地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚；

《行政处罚法》第十二条：

地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。

法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。

法律、行政法规对违法行为未作出行政处罚规定，地方性法规为实施法律、行政法规，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形

式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。地方性法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。

(4) 【注意】（部门或地方政府）**规章原则上不享有行政处罚的设定权**，只是在以下两种特殊的情况下才享有有限的设定权：

一是可以在法律、法规规定给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体的规定；二是在法律、法规没有设定行政处罚的领域，规章可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。

3. 行政处罚的实施和适用规则：**过罚相当原则**【类似比例原则】（必考）

《行政处罚法》第五条第二款规定：“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当”。

(1) 要求1: **处罚应当有事实依据**【先有事实】

【案例】某省道路交通管理部门在解决机动车超载的执法检查活动中，个别行政执法人员，让运煤的车主先交一个月的超载罚款，理由是，免得天天停车检查、交罚款费事，当地群众称之为“罚款买月票”。

【问题】这种做法是否合法，为什么？——否。与立法目的背道而驰，起不到让相对人认识行为违法性和危害性的作用

(2) 要求2: **合理行使行政裁量权**

在处罚法定的基础上，针对违法行为的不同情节、社会危害程度、违法构成要件以外的事实，如事后行为、处罚目的、社会效果、国家当前的政策等诸因素综合考虑，做出符合“过罚相当”原则的行政处罚决定。

【给狗取名城管被拘留】限制人身自由的行政措施与其产生的社会危害性程度严重不符

【老农卖芹菜获利14元遭天价罚款】根据《食品安全法》，销售1w元以内的不合格的产品，处5w以上10w以下的罚款。该罚款于法有据，但其社会危害性与畸重的处罚不相符。

(3) 处罚幅度

《行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：

- (一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；
- (二) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；
- (三) 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；
- (四) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；
- (五) 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。

① 从轻罚款，是行政机关对行政相对人实施的违法行为在法定罚款幅度的中等线以下至最低幅度以上的处罚。

② 减轻罚款，是行政机关对行政相对人实施的违法行为在法定最低幅度以下的罚款。

③ 从重罚款，是行政机关对行政相对人实施的违法行为在法定罚款幅度的中等线以上至最高幅度内的处罚。

④ [加重罚款]超越权限的违法行为

(4) **不予行政处罚**（考）

《行政处罚法》第33条第一款【明确首违不罚的制度】：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

首违不罚的条件：

① **初次违法**：有些地方出台的文件对“初次”的认定有期限规定，如一年内初次违法的不予处罚；更多的是无期限的追诉

② **危害后果轻微**：可量化的尽量量化，无法量化的以情节轻重，持续性的以时间长短

③ **及时改正**：改正的期限+效果（恢复到违法行为发生之前的状态）

(5) 简易程序：

A. 适用条件：

① 违法事实确凿。

② 有明确的法定依据。

③ 符合《处罚法》规定的处罚种类和幅度。种类有两种：警告和罚款（对公民处以200元以下，对法人或者其他组织处以3000元以下的罚款）

B. 基本步骤：表明身份（同样是至少2人参与）、告知当事人相关事项及权利、听取申辩、填写行政处罚决定书、备案。

(6) 一般程序



(7) 听证程序（行政处罚公开原则的制度体现）

A. 举行听证程序的范围

《行政处罚法》第六十三条 行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：

（一）较大数额罚款；

- (二) 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；
- (三) 降低资质等级、吊销许可证件；
- (四) 责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- (五) 其他较重的行政处罚；
- (六) 法律、法规、规章规定的其他情形。

当事人不承担行政机关组织听证的费用。

B. 听证程序

告知听证权利。

当事人应当在行政机关告知后的5日内提出听证要求。

应当事人要求而举行听证。

通知听证的时间、地点。

听证程序的主持人（无利害关系）和参加人。

公开听证（除非涉及国家秘密、商业秘密）与回避。

当事人有权进行申辩和质证。

听证应当制作笔录，并交当事人审核无误后签字或者盖章。

听证结束后，行政机关应当根据听证笔录作出决定。

八、行政强制法

1. 行政强制的设定权（比许可权、处罚权的设定更严格：权力太强大，对当事人带来的影响十分明显）

行政强制的设定权是指拥有设定行政强制权的机关创设行政强制，使行政强制权从无到有的过程，它是特定机关通过制定法律规范创设行政强制权的法律活动过程，从其本质层面而言，则是特定机关创设行政强制权的权限划分。

(1) 法律可以设定各类行政强制措施和行政强制执行。

(2) 尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制人身自由、冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。（不可设定强制执行）

(3) 尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或财物、扣押财物两项行政强制措施。（不可设定强制执行）

(4) 规章，无论是国务院部门规章，还是地方政府规章，均不得设定任何行政强制措施。规章以外的其他规范性文件则更不具有行政强制措施设定权。（不可设定强制执行）

(5) 法律对行政强制措施的对象、条件、种类作了规定的，行政法规、地方性法规不得作出扩大规定；法律中未设定行政强制措施的，行政法规、地方性法规不得增设行政强制措施。（不可扩张设定权，上位法不设定的即认为没有必要设定）但是，法律规定特定事项由行政法规规定具体管理措施的，行政法规可以设定除限制人身自由、冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。

(6) 行政强制执行均只能由法律设定，行政法规、地方性法规、规章均不得设定行政强制执行。【法律保留事项】

2. 如何区分行政强制措施和行政强制执行：**注重程序和对象的区别**

	适用目的	主要类型	主要依据	法律后果
行政措施 (实施主体：法律法规明确授权的行政主体)	①调查 ②预防 ③征用	对人强制扣押、隔离；对物强制检验、查封、扣押、冻结；对场所强制隔离、查封	不以义务人不履行义务为必要前提，因目的不同而不同	暂时性控制
强制执行 (实施主体：行政机关和人民法院)	保证法定义务的履行	间接强制如代履行、执行罚；直接强制如划拨、收缴、拍卖	相对人逾期不履行义务	对当事人权利的一种长时间剥夺

强制执行是为了让没有履行法定义务的相对人履行法定义务或达到履行法定义务的状态；强制措施的实施并不以相对人负有法律义务为前提，强制执行是以相对人负有法律义务为前提，典型如违章建筑

3. 强制措施的程序——尤其催告等特别程序

作出行政强制执行决定前，应当“催告”。

【未催告、未作出强制执行决定、未告知当事人诉权，导致强制措施违法】只能确认违法，难以撤销

4. 我国的行政强制执行主体——**双轨制**

(1) 行政机关

(2) 法院

《行政强制法》第13条：法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请人民法院强制执行。

《行政诉讼法》第66条：公民、法人或者其他组织对具体行政行为在法定期间不提起诉讼又不履行的，行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。

让法院承担执行工作，导致同期诉讼案件数量激增，法院难以处理大量执行工作，且导致矛盾转移至法院

→裁执分离（裁定权、确认权在法院手中，真正实施的是行政机关。由征收补偿领域逐渐扩展）

九、其他行政行为

行政检查、行政征收、征用、行政协议、行政给付、行政奖励等，包括事实行为（具体概念列举见第零点，要能够判断）

十、行政程序（link正当程序原则）

《政府信息公开条例》

1. 主动公开和依申请公开，依申请公开更重要：

（1）主动公开的范围

《政府信息公开条例》第十九条 对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息，行政机关应当主动公开。

《政府信息公开条例》第二十条 行政机关应当依照本条例第十九条的规定，主动公开本行政机关的下列政府信息：……

（2）政府答复形式的条件，什么时候可以不予公开：我国目前是公开为原则，不公开为例外，除了法定不可公开的信息，其余基本都要公开

① 不予公开政府信息范围的规定

《政府信息公开条例》第14条：依法确定为国家秘密的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息，不予公开。

第15条：涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息，行政机关不得公开。但是，第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的，予以公开。

② 可以不予公开政府信息

《信息公开条例》第16条第一款【可以不公开，行政机关裁量】行政机关的内部事务信息，包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息，可以不予公开。

属于行政机关内部事务信息；讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息【决定作出前的内部信息】；行政执法案卷；工商登记资料、不动产登记资料等其他法律或行政法规规定了专门查询办法的信息。可以不公开。

3. 注意所有性质的行为的听证和陈述有关的程序